

1502823-19.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502823-19.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502823-19.2020.8.26.0050, c. 360/20

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2029418/2020 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 9794559 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

708/20/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2029418 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 708/20/103

- 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AYOUB HIBAQUI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

AYOUB HIBAQUI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 31 de janeiro de 2020, por volta das 16h, na Rua Guaianases, nº 60, República, São Paulo - SP, subtraiu, para si, 01 telefone celular LG K10, avaliado em R\$1.000,00, de propriedade da vítima O. A. B. A denúncia foi recebida em 02 de março de 2020 (fls. 67). O réu foi citado pessoalmente (fls. 103) e ofereceu resposta à acusação (107/108). Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas arroladas em comum,

sendo o acusado interrogado nesta data. Não foram requeridas novas diligências. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Em relação às penas, pleiteou a elevação da pena base pelos seu mau antecedente, fixação de regime prisional mais gravoso e não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade material decorrente do Princípio da Insignificância. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da figura privilegiada, a fixação das penas no mínimo legal, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A vítima disse que na época dos fatos era cobrador de ônibus e estava trabalhando no coletivo, quando parou em um farol. O depoente tirou o aparelho de sua mochila e o colocou sobre a gaveta de dinheiro. Virou-se para colocar a mochila no banco e escutou um barulho, percebendo que seu celular havia sido subtraído. Imediatamente, alguns passageiros e o depoente saíram no encalço do furtado. Não conseguiu ver a fisionomia dele no momento da subtração, mas durante a perseguição conseguiu visualizá-lo claramente. Não o perderam de vista, até que ele virou uma esquina e quando viraram foram alertados por populares que ele estava embaixo de um carro. Ele não queria sair de baixo do veículo, até que foi retirado por algum popular. Ele falava com dificuldade o idioma nacional, mas indicou onde estava o aparelho do depoente, que foi recuperado no local por ele indicado, mas com danos. Em seguida, chegaram policiais que efetuaram a prisão dele.

O policial militar Nilton declarou que não se recordava com detalhes da ocorrência. Informou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu correndo, sendo que transeuntes passaram a gritar que ele teria subtraído um aparelho celular. Foram no encalço dele e o abordaram. Não se recordava de ele ter sido abordado por populares antes. O aparelho foi encontrado atrás de um carro. Acredita que a localização do aparelho foi por conta de varredura e não porque o réu indicou. Não se recorda se o réu tentou se esconder. A vítima compareceu e informou que havia perseguido o indivíduo, reconhecendo-o como autor do delito. O réu confessou a prática delitiva. O policial militar Henrique não se recordava dos fatos tratados nestes autos. O réu não foi interrogado porque é revel.

Em que pese o suscitado pela defesa, existem elementos suficientes a comprovar a autoria delitiva em desfavor do acusado. Em que pese não tenha comparecido em audiência, tornando-se revel, a vítima ponderou que o reconheceu sem sombra de dúvida no dia dos fatos, mesmo porque perseguiu-o e o deteve logo após a subtração, quando estava escondido embaixo de um veículo, esclarecendo que foi o réu quem indicou a localização do aparelho, que foi encontrado no local indicado, com danos, não havendo qualquer elemento a infirmar suas palavras.

Em função do tempo decorrido, um dos policiais não se recordava da ocorrência e o outro recordava-se sem detalhes. As pequenas divergências havidas entre o depoimento de Nilton e o da vítima não justificam a absolvição, já que as inconsistências dizem respeito a aspectos marginais, que não comprometem a higidez geral de seus depoimentos.

Em relação à pretensão de aplicação do princípio da insignificância, que seria causa supralegal de exclusão de tipicidade, pois a conduta não representaria ofensa material ao bem jurídico tutelado, deve-se diferenciar bem de ínfimo valor de bem de baixo valor. Aquele é capaz de configurar a aplicação da teoria da bagatela, mas, na visão desta magistrada, só pode ser aplicado a bens de inexpressivo valor, bens que, na verdade, nem poderiam receber uma valoração material. Já os bens de valor irrisório podem, eventualmente, configurar a hipótese tratada no artigo 155, § 2º, do Código Penal, desde que estejam presentes os demais requisitos.

Assim, a questão fundamental é enquadrarem-se os bens subtraídos na qualidade de bem de insignificante valor material. Nesta esteira, reputo que tal não possa ser feito. Ora, vivemos em um país em que não se pode considerar que o montante de R\$1.000,00 seja insignificante. Frequentes são os casos em que acordos em ações de alimentos não são firmados por divergência de valores bem inferiores a este. Anualmente o governo federal concede aumento do salário mínimo em montante inferior

ao tratado nestes autos. Seria justo afirmar a um trabalhador que o valor que recebeu de aumento, após um ano de espera, é ínfimo?

Ademais, o parâmetro para a incidência do princípio em questão é objetivamente o valor do bem e não o montante do eventual prejuízo sofrido pela vítima, o que significa dizer que o fato de o bem ter sido restituído à vítima (por ato não voluntário do réu) não acarreta a incidência da excludente pretendida.

Elucidativa a seguinte transcrição de recente decisão do E. STJ, que pacificou o entendimento de que irrisório é apenas o que tem valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos:

"(...) 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. No presente caso, o valor dos bens subtraídos (R\$ 120,00) ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época da prática delitiva (2011 - R\$ 545,00), não podendo ser considerado irrisório, razão pela qual não está preenchida condição essencial à aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1650873 / MG, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 28/03/2017). Afora a questão do valor do bem, tem-se que o réu responde por outros delitos patrimoniais (fls. 146/147), o que também impede a aplicação do chamado princípio da insignificância. Com efeito, em acórdão que estabeleceu os limites da incidência de tal princípio para fins de afastamento da tipicidade da conduta, o Ministro Celso de Mello, do E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 84.412/SP, assentou que quadro são os requisitos, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, não se trata de uma simples aferição do valor da coisa, mas também da personalidade do autor da subtração, o qual vem demonstrando sua tendência em reiterar a conduta delitiva, especialmente quanto aos crimes patrimoniais.

No entanto, é o caso de se reconhecer a figura privilegiada, na medida em que o réu não era reincidente (é portador de mau antecedente, como será visto adiante) e o valor do celular é inferior ao do salário mínimo então vigente, sendo este o parâmetro estabelecido pelo E. STJ para fins de avaliação de incidência do privilégio.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima descritos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, eis que detentor de mau antecedente (10ª VC, autos 0001987-82.2018.8.26.0635, com fatos em 24/02/2018 e que transitou em julgado para a defesa em 29/08/2021 - fls. 152), motivo pelo qual suas penas serão elevadas em 1/6, ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Plenamente viável o reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, já que se refere a fato que ocorreu antes dos fatos tratados nestes autos. Neste sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO PATAMAR

DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO AFASTADA. VIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEASCORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. (...) (grifei) (STJ, HC 270685/SP, HABEAS CORPUS, 2013/0155080-7, Relatora Ministra LAURITA VAZ)

Em função do privilégio, as penas será reduzidas em 1/3, ficando em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Deixo de aplicar a pena de multa com exclusividade porque, embora primário, é portador de mau antecedentes e ostenta outra condenação já transitada em julgado por fato posterior.

Diante do quantum de pena, fixo-lhe o regime inicial aberto.

Inviável eventual benefício do ANPP, porquanto detentor de mau antecedente, bem como responde por outros delitos, nos termos do artigo 28-A, §2º, inciso II, do CPP.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 155, caput, c.c. § 2º, do Código Penal, o réu AYOUB HIBAQUI, às penas de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo cada dia-multa no mínimo legal.

Pelos mesmos motivos que levaram à não aplicação da pena de multa com exclusividade quando da análise da figura privilegiada, entendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante do quantum de pena e o regime inicial aberto, não vislumbro os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Assim, defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 113/114.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA